

1500094-17.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... - devendo o réu ser condenado por trafico. Todavia, absolve-se por atipicidade a mera posse de apenas DUAS munições isoladas, SEM QUE O AGENTE DISPONHA de qualquer armamento ou qualquer equipamento que fosse apto a deflagrá-las. Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1500094-17.2020.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-17.2020.8.26.0536 (2020/000034)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

CF, CF, BO, CF, BO

2006538/2020, 9393900, 258/20/203, 2006538, 258/20/203 - DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIUDENGARDSON DIAS DE SOUSA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

LIUDENGARDSON DIAS DE SOUSA, qualificado nos autos a fls. 03, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Consta da denúncia que no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 11h30, na Rua Afonso Teixeira Vidal, altura do nº 45, Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Guarujá, guardava e trazia consigo, para fins de entrega à consumo de terceiros, 02 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas, da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 60 gramas, 03 porções individuais, da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 495 gramas, 05 porções individuais, em forma de pedra, do resultado do subproduto do refinamento do estupefaciente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecido como Crack, pesando aproximadamente 05 gramas, e 10 porções individuais, em forma de comprimidos, da substância entorpecente metilenodioximetanfetamina, vulgarmente conhecida como ECSTASY, pesando aproximadamente 05 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, possuía e tinha em depósito 02 munições, calibre 40, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de

prisão em flagrante fls. 1-2, boletim de ocorrência fls. 3-5, auto de exibição/apreensão/entrega fls. 11-12, auto de constatação preliminar 13-14, antecedentes do réu a fls. 28-31, relatório da autoridade policial fls. 48-50; laudo pericial (munição, balança e caderno) a fls. 283-295; Exames Químico-Toxicológicos fls. 297 e 304.

Em 09/01/2020 na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva fls. 34-37. Foi concedida liberdade provisória ao réu em fls. 160-161. O Alvará de soltura foi cumprido em 09/07/2020 fls. 174. (Esteve preso de 08/01/2020 a 09/07/2020, cerca de 6 meses em regime fechado)

A denúncia foi oferecida em 10/01/2020 fls. 44-47 e recebida em 13/02/2020 fls. 89. A Defesa apresentou resposta à acusação em 05/02/2020 fls. 58-73.

Durante a instrução, na audiência realizada em 16/03/2020 fls. 106-107 foi ouvida a testemunha PC THIAGO MÁXIMO fls. 108. Na audiência realizada em 06/08/2021 fl. 242, foram ouvidas a testemunha comum, PC MARCELO JOÃO fl. 243, duas testemunhas de defesa, INGRIDY DIAS fl. 244 e TATIANE APARECIDA fl. 245, bem como foi interrogado o réu LIUDENGARDSON fl. 246. Link das oitivas a fls. 247.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em 03/09/2021 fls. 251-282, requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, a majoração da pena em razão de Maus Antecedentes e reincidência fls. 237-240, o regime inicialmente fechado e o perdimento de bens apreendidos em favor da União.

A Defesa apresentou alegações finais em 26/01/2022 fls. 313-326, requerendo que a presente seja julgada parcialmente procedente, desclassificando a capitulação descrita na denúncia para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, requereu subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da reprimenda, disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), afastando-se a incidência da Lei nº 8.072/90, fixando-se o regime prisional nos moldes do disposto no art. 33, §3º, c. c. o art. 59, assim, tendo em vista que a pena aplicada não será superior a 4 (quatro) anos, considerando as condições judiciais favoráveis do acusado, aplicando-se o regime aberto, consoante dispõe a alínea `c` do §2º, do art. 33 do Código Penal e, conseqüentemente, convertendo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal; - devendo o réu ser condenado por tráfico. Todavia, absolve-se por atipicidade a mera posse de apenas DUAS munições isoladas, SEM QUE O AGENTE DISPONHA de qualquer armamento ou qualquer equipamento que fosse apto a deflagrá-las.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência fls. 3-5, auto de exibição/apreensão/entrega fls. 11-12, auto de constatação preliminar 13-14, laudos periciais de fls. 283-304, bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PC THIAGO MÁXIMO, quando ouvida em Juízo fl. 108, narrou que, na data dos fatos, realizou diligência na residência do réu e apreendeu as drogas e as munições. Disse que tinha denúncia de que o réu, vulgo "Liu", traficava em um local próximo e armazenava as drogas em sua casa. Afirmou que foi até o local para checar a veracidade da residência e, ao chegar no local, o réu os recebeu e franqueou a entrada. Asseverou que, após as buscas, encontrou as drogas descritas na denúncia.

Declarou que também apreendeu uma balança de precisão, caderno de anotações e pó branco. Informou que o réu, sobre as drogas menores, declarou que era usuário e, sobre as drogas a granel, disse que estavam guardadas e que iria jogar fora afirmou que essa parte da droga tinha aspecto de mofado, que aparentava estar guardava a bastante tempo. Asseverou que somente o réu estava no imóvel. Disse que não encontrou documento do réu no local. Declarou que o imóvel era habitável, uma cozinha e um quarto. Informou que a droga. Informou que as drogas estavam espalhadas pelo imóvel. Declarou que as munições foram encontradas em um armário.

A testemunha PC MARCELO JOÃO, quando ouvida em Juízo fl. 243, narrou que o réu, vulgo "Liu", era conhecido por traficar pelo bairro do Santa Rosa, que, na data dos fatos, recebeu informações de que o réu morava e armazenava drogas no local dos fatos. Informou que se deslocou até o local denunciado, encontrou a última residência do terreno com a porta aberta, foi atendido pelo réu. Disse que o réu franqueou entrada aos policiais e no interior do imóvel localizou os entorpecentes e as munições de calibre 40. Afirmou que apreendeu também uma balança de precisão, caderno com anotações e pó branco utilizado para fazer volume com cocaína. Declarou que o réu negou a propriedade das drogas. Receberam denúncia de que "Liu" armazenava drogas no local e foram averiguar. Informou que era de seu conhecimento que pessoa com esse vulgo praticava tráfico na região, mas não conhecia sua qualificação, não sabia quem era. Narrou que nunca abordou o réu antes dos fatos. Asseverou que as drogas estavam separadas pelo imóvel e as munições estavam no guarda-roupa. Declarou que não apreendeu documentos pessoais ou contrato de locação no local.

A testemunha de defesa, INGRIDY DIAS, quando ouvida em Juízo fl. 244, disse que o réu é seu amigo, disse que não sabe onde ele mora, que ele é usuário de maconha há uns oito anos, já viu ele usando maconha, nunca foi na casa do réu onde ele reside por cerca de quatro anos.

A testemunha de defesa TATIANE APARECIDA, quando ouvida em Juízo fl. 245, disse que não tem amizade íntima com o réu. Disse que conhece o réu há bastante tempo que ele é usuário de maconha, já viu ele usando maconha.

O réu LIUDENGARDSON, quando ouvido em Juízo fls. 246, disse que tem 35 anos e que estudou até o ensino médio completo, trabalha de lava rápido e motoboy. Sobre os fatos disse que não morava no local, apenas se encontrava com seus amigos no local para fumar maconha que na data dos fatos, foi até o local, fumou maconha e acabou dormindo na casa. Afirmou que mora há mais de dez anos em uma casa na rua paineiras no jardim las palmas, estava sozinho no momento em que foi acordado pelos policiais. Asseverou que as drogas e as munições apreendidas não eram do depoente. Declarou que não possui arma de fogo e nem sabia que tinha munição no local. Disse que viu em um balde na casa uma maconha que estava estragada, mas que não tem o controle da casa é apenas viciado.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado LIUDENGARDSON DIAS DE SOUSA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico e posse de munição de arma fogo previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Perante a Autoridade Policial (fls. 8), o réu alegou "que as substâncias apreendidas realmente estavam em sua casa, só que elas estão estragadas sem condição de uso. Que tinha deixado elas guardadas em um balde, era para ter jogado fora. Das substâncias apenas os tabletes de maconha estão em condições de uso e são para seu uso pessoal, é usuário de maconha e também de ecstasy. Que nesta manhã estava em sua casa quando chegaram dois policiais e encontraram os objetos disseram que eram drogas e o trouxeram para a delegacia. Que algumas pessoas lhe chamam pelo apelido de LIU. Quanto aos dois projéteis de arma de fogo, alega que os encontrou em via pública e iria fazer um pingente para uso próprio."

Em que pese a negativa do réu, por ocasião de seu interrogatório, temos que a negativa do réu se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando o réu como autor do delito em

questão, não havendo dúvida acerca de seu envolvimento com a droga e as munições apreendidas.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional. Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar o réu. Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado LIUDENGARDSON DIAS DE SOUSA, guardava e possuía em depósito as drogas para fins de entrega a consumo de terceiros, sendo impossível acolher a pretensão absolutória, bem como não é possível acolher a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, em razão da incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo, tendo em vista a apresentação e quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão.

Quanto ao crime de porte ilegal de duas (2) singelas munições de calibre 40 - reputo que o fato torna-se ATÍPICO, no contexto do fato concreto aqui apurado, eis que o AGENTE NÃO DISPUNHA DE NENHUM ARMAMENTO, não dispunha de nenhum meio de maquinário hábil para fazer deflagrar os estojos apreendidos, não havendo portanto lesividade na conduta.

Em se tratando do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, umpelo os quais o acusado Liudengardson está sendo processado, em razão de duas munições íntegras (laudo às fls. 284, 286), as quais foram encontradas em sua residência durante diligências policiais, não se tem risco ao bem jurídico tutelado, a segurança pública, tornando-se atípica a conduta do agente. Pela leitura do Estatuto Armamentista, a posse de munição seria de perigo abstrato, ou seja, a situação de perigo é presumida, havendo punição do agente mesmo que ele não tenha arma de fogo.

Neste ponto, contudo, destaca-se o Princípio da Ofensividade, segundo o qual não há ofensa ao bem jurídico tutelado, quando da infração penal não houver resultado efetiva lesão ou real perigo de lesão ao bem jurídico.

Por consequência disto, não há delito quando a conduta não oferece perigo concreto e real, quando não há risco de produzir resultado lesivo ao bem jurídico; devendo todo tipo penal fundado literalmente em perigo abstrato, ser interpretado e adequado à visão constitucional do Direito Penal.

Outra não é a lição dos doutrinadores Luiz Flávio Gomes e William Terra de Oliveira, para quem: sob a ótica de um direito penal razoável e equilibrado em termos de intervenção, e buscando um sistema penal que confira prestígio ao princípio da ofensividade, a análise da real lesividade da conduta é sempre um requisito inafastável... O princípio da ofensividade está encartado na idéia de "lesividade" e pode ser expresso, sinteticamente, pela idéia de que não existe delito sem lesão, ou perigo de lesão, ao bem jurídico protegido (in Lei das Armas de Fogo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 71)

Para Luiz Flávio Gomes: "(...) munição desarmada (leia-se: munição isolada, sem chance de uso por uma arma de fogo) assim como a posse de acessórios de uma arma. Não contam com nenhuma danosidade real. São objetos (em si mesmos

considerados)absolutamente inidôneos para configurar qualquer delito."

No mesmo sentido dispõe Ferrajoli: "(...) por exemplo, um cartucho de munição para nada serve se não houver arma que ele fará uso. (...) Assim, como a arma de fogo precisa estar municiada para trazer perigo à coletividade, a munição, sem a arma, também não produz qualquer efeito, uma vez que quem mantém em seu poder um número grande de armamento, desde que desmuniados estaria concorrendo para a prática do artigo 180 ou 334 do Código Penal."

Assim, como medida de política criminal, em caso de apreensão ISOLADA de uma ou duas munições, desacompanhadas de arma, ou seja, sem possibilidade de utilização instantânea, não enseja caracterização do crime em questão, pois a vigência entre nós do princípio constitucional da ofensividade, que impõe limitação ao legislador infraconstitucional. Entendimento que já foi admitido em precedentes do Pretório Excelso,in verbis: "Para a teoria moderna - que dá realce primacial aos princípios da necessidade da incriminação e da lesividade do fato criminoso - o cuidar-se de crime de mera conduta - no sentido de não se exigir à sua configuração um resultado material exterior à ação - não implica admitir sua existência independentemente de lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico tutelado pela incriminação da hipótese de fato. É raciocínio que se funda emaxiomas da moderna teoria geral do Direito Penal; para o seu acolhimento, convémfrisar, não é necessário, de logo, acatar a tese mais radical que erige a exigência da ofensividade a limitação de raiz constitucional ao legislador, de forma a proscrever a legitimidade da criação por lei de crimes de perigo abstrato ou presumido: basta, porora, aceitá-los como princípios gerais contemporâneos da interpretação da lei penal, que hão de prevalecer sempre que a regra incriminadora os comporte. Na figura criminal cogitada, os princípios bastam, de logo, para elidir a incriminação do porte da arma de fogo inidônea para a produção de disparos: aqui, falta à incriminação da conduta o objeto material do tipo. Não importa que a arma verdadeira, mais incapaz de disparar,ou a arma de brinquedo possam servir de instrumento de intimidação para a prática de outros crimes, particularmente, os comissíveis mediante ameaça - pois é certo que, como tal, também se podem utilizar outros objetos - da faca à pedra e ao caco de vidro - cujo porte não constitui crime autônomo e cuja utilização não se erigiu em causa especial de aumento de pena. No porte de arma de fogo desmuniada, é preciso distinguir duas situações, à luz do princípio de disponibilidade: (1) se o agente traz consigo a armadesmuniada, mas tem a munição adequada à mão, de modo a viabilizar sem demorasignificativa o municiamento e, em consequência, o eventual disparo, tem-se armadisponível e o fato realiza o tipo; (2) ao contrário, se a munição não existe ou está emlugar inacessível de imediato, não há a imprescindível disponibilidade da arma de fogo,como tal - isto é, como artefato idôneo a produzir disparo - e, por isso, não se realiza a figura típica.(RHC nº 81.057/SP, 1º Turma, rel. min. Ellen Gracie, rel. acórdão min.Sepúlveda Pertence, j. 25.05.04, v.u., DJU 29.04.05)

Pelo acima justificado, excepcionalmente, ABSOLVO o réu LIUDENGARDSON DIAS DE SOUSA em relação ao crime previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, por atipicidade material na situação da haver apreensão de somente uma ou duas munições sem existir qualquer armamento à disposição do réu.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, comprovada a responsabilidade criminal do acusado LIUDENGARDSON DIAS DE SOUSA, passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu é portador de maus antecedentes criminais (fls. 231-241; fls. 28-29).

Em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, Devido aos maus antecedentes criminais do réu (fls. 231-241), ele não faz jus ao benefício redutor do §4 do Art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, sua pena fica para o delito de trafico fica mantida em 5 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa.

O regime inicial deverá ser o FECHADO.

O réu faz jus à detração, que será aferida pela VEC competente, oportunamente.

Devido aos maus antecedentes do réu, indefere-se a conversão em penas alternativas, pois não seria pedagogicamente suficiente, nem socialmente útil tal conversão.

O réu apela SOLT0.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para: (a) CONDENAR o réu LIUDENGARDSON DIAS DE SOUSA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, nas penas de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (Quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente Fechado, apelando solto, sem direito a conversão em penas alternativas. E ao mesmo tempo, (B) ABSOLVER o réu Liudengardson Dias de Souza, unicamente no que se refere à imputação do crime do Artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse de duas munições isoladas, sem dispor de qualquer armamento apto a deflagrá-las), reconhecendo-se excepcionalmente a atipicidade desta parte da denuncia; o que faço com fulcro em CPP art. 386, inciso VI.

Por fim, (c) Autorizo e determino a destruição urgente das drogas e apetrechos apreendidos; e bem assim, decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Apos o transito em julgado, expede-se mandado de prisão.

PRIC. Guaruja, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA